

权要求承租人交还租赁物或支付 占有使用费。在次承租人不能支付占有使用费的情况下，出租人仍然可以要求 承租人支付占有使用费，并未丧失救济途径。虽然在承租人本身缺乏履行能力 的情况下，出租人实际受偿可能难以实现，但这属于出租人选择承租人本身含 有的风险，不能因此否认善意次承租人的抗辩权。

3. 在具体判断次承租人是不是善意时，应当注意以下两个方面： 一是次承 租人给付租金之时是否知道或者应当知道承租人已无转租权。出租人和承租人 协议终止合同导致承租人无转租权的， 一般情况下属于次承租人无法预料的情 形，若出租人或承租人未告知次承租人该情形，而次承租人依约支付租金的， 属于善意。本案中，经出租人甲公司允许，丙公司于2021年3月转租房屋给乙 公司，故乙公司无法预料甲公司与丙公司将于2021年7月解除合同。相反，如 果出租人或承租人已经就双方终止合同的情况明确告知或者提示了次承租人， 而次承租

人仍然向承租人支付租金的，则不构成善意。二是次承租人交纳租金 是否符合合同约定。租赁合同约定的租金交纳方式一般分为先付后租和先租后 付两种形式。无论哪种形式，次承租人如果是按照租赁合同的约定交纳租金， 均是其诚信履约的表现。而如果次承租人提前支付租金或者超额支付租金，扩大了其租金支付风险，使得出租人的租金或占有使用费请求权不能从承租人处 获得救济时，次承租人本不应向承租人交纳的租金因其提前支付或超额支付而

已经实际支付的，次承租人应当承担该不审慎的后果，不能主张其为善意，应当向出租人支付相应的占有使用费，再根据与承租人的转租合同关系，请求承租人返还相应的费用。

编写人：江苏省南京市中级人民法院 马帅

(二) 返还原物纠纷

12

欠缺形式要件的“居住权”与所有权冲突情形下之权利保护

——杜某诉申某甲返还原物案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2023)京02民终2068号民事判决书

2. 案由：返还原物纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 杜某

被告(被上诉人): 申某甲

【基本案情】

1978年，杜某与申某甲登记结婚，婚后育有一女申某乙。2003年，杜某与申某甲经法院调解离婚。2002年，某房地产开发有限公司与申某乙签订《商品房买卖合同》，申某乙购买案涉房屋。后申某乙取得房屋所有权。该房屋从开发商处交付后先由杜某与申某乙居住使用。2008年申某乙结婚，其从该房屋内

搬出，同年申某甲搬入，与杜某共同居住。2016年杜某搬走。申某甲继续在该房屋内居住使用至今。2020年7月，申某乙将案涉房屋过户至杜某名下。就案涉房屋购房款出资情况，除申某乙认可申某甲给付其8万元用于偿还贷款外，二人各执一词，双方对付款情况均未提交相应证据。

2018年12月，申某乙（甲方）为申某甲（乙方）出具一份《保证书》载明：甲方案涉房屋无条件让乙方使用，包括居住、出租至死。甲方将此房转至杜某名下，乙方同样享有房屋使用权。一旦杜某不让乙方居住，乙方有权找甲方协商解决。落款处申某乙在保证人处签字。杜某对《保证书》的真实性予以认可，但认为这是申某乙与申某甲协商过程中形成的材料，未得到双方认可，故并未生效。申某乙认可保证书的真实性，但认为保证书系其父亲偷偷留存。申某甲对偷偷留存一说不认可，表示申某乙只给其写过这一份保证书。庭审中，杜某与申某乙均表示杜某不知道保证书的存在。

【案件焦点】

1. 申某乙的单方允诺行为能否为申某甲创设居住权；2. 申某甲未经登记的居住权能否对抗房屋所有权继受人杜某。

【法院裁判要旨】

北京市丰台区人民法院经审理认为：案涉房屋现所有权人为杜某。杜某自述其权利来源为其女儿申某乙的赠与行为。而申某乙在房屋过户于杜某前曾于2018年为其父亲申某甲出具保证书，该保证书的内容应为申某乙对申某甲享有案涉房屋居住权的承诺。虽然当时的法律、司法解释没有居住权的相关规定，但是按照“空白溯及”的原则，理应适用《中华人民共和国民法典》居住权的相关规定。该居住权的承诺未在房屋登记机关进行备案登记，没有依法设立，不产生对外公示效力，但对承诺人申某乙具有约束力。杜某作为房屋的继受人，一

则与申某乙之间存在母女关系，二则对该房屋的原始取得情况、房屋购买时的出资情况以及房屋长期以来的实际居住使用情况均应明知。虽其称对该房屋上的申某甲居住权的权利设定并不知情，但无法就此认定其为善意取得，故认

为其物权权利不得对抗申某甲的居住权，对其要求申某甲搬离并返还房屋的诉讼请求，不予支持。

北京市丰台区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第三百六十六条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第三条规定，判决如下：

驳回杜某的诉讼请求。

杜某不服一审判决，提起上诉。

北京市第二中级人民法院经审理认为：本案的争议焦点为申某甲是否应搬离案涉房屋，对此法院持否定意见，理由如下：案涉房屋原登记所有权人申某乙出具的《保证书》明确申某乙享有案涉房屋的居住使用权，且预设此房转至杜某名下时申某甲仍享有居住使用权的情形。申某乙将案涉房屋过户至杜某名下后，按照案涉《保证书》记载的内容，申某甲此时亦享有案涉房屋的居住使用权。申某乙在一、二审庭审时均认可《保证书》的真实性，虽其认为该保证书为协商过程中产生的文字材料，并非其真实意思表示，但没有相关证据予以佐证，对该辩称意见，不予采信。故，申某甲居住使用案涉房屋有合理依据，一审法院判决驳回杜某要求申某甲搬离并返还房屋的诉讼请求正确，予以维持。

北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

《中华人民共和国民法典》第一次在我国法律体系中创设了居住权制度。作为一项新型的民事权利，这一制度的出现势必会对民众的切身利益、婚姻家庭、财产安全产生重大影响。因此，设立形式要件欠缺且未予登记的居住权是否应当保护，应当构建怎样的裁判规则，是审判实践中需要迫切解决的问题。

一、房屋所有权人通过单方允诺行为为他人设立居住权之合理性

《中华人民共和国民法典》对于居住权的设立方式，仅规定了合同和遗嘱

两种方式，①且对于合同的形式也明确规定为书面形式，对居住权合同的内容也进行了规定。②可见，《中华人民共和国民法典》对于设立居住权合同的形式采取的是要式合同的原则。那么，房屋所有权人的单方允诺书能否为他人设立居住权？笔者认为，当事人可以基于双方合同约定获得居住权，亦可以基于所有权人的单方允诺行为而设立居住权。

首先，民事法律行为可以基于双方或多方的意思表示一致成立，也可以基于单方的意思表示成立。③故，民事法律行为可以划分为合同行为以及单方法律行为。虽然合同并不包括单方法律行为，但如果仅仅为强调合同的形式，就对意思表示明确但欠缺形式要件的单方法律行为一律给予否定评价，则会极大影响交易的安全与稳定。

其次，单方法律行为可以通过一定的补救措施使其具备合同效力。《中华人民共和国民法典》之所以要求当事人必须以书面形式订立居住权合同，其立法本意基于三点：一是保存证据，留待发生争议时有据可查；二是明确合同内容，便于当事人依据约定行使权利履行义务；三是便于办理物权变动登记手续。在单方承诺下，上述内容都可以通过当事人自认与履行进行补救。根据《中华人民共和国民法典》第四百九十条第二款规定④，我国法律追求的是信赖利益，而非要式目的。单方承诺书可以通过当事人自认形成双方合意。当事人自认可

①《中华人民共和国民法典》第三百六十六条规定，居住权人有权按照合同约定，对他人的住宅享有占有、使用的用益物权，以满足生活居住的需要。第三百七十一条规定，以遗嘱方式设立居住权的，参照适用本章的有关规定。

②《中华人民共和国民法典》第三百六十七条规定：“设立居住权，当事人应当采用书面形式订立居住权合同。居住权合同一般包括下列条款：（一）当事人的姓名或者名称和住所；（二）住宅的位置；（三）居住的条件和要求；（四）居住权期限；（五）解决争议的方法。”

③《中华人民共和国民法典》第一百三十三条规定，民事法律行为是民事主体通过意思表示设立、变更、终止民事法律关系的行为。第一百三十四条第一款规定，民事法律行为可以基于双方或者多方的意思表示一致成立，也可以基于单方的意思表示成立。

④《中华人民共和国民法典》第四百九十条第二款规定，法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立，当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务，对方接收时，该合同成立。

以采取多种形式，如在法庭上的答辩、作证、书面承认等。本案中，对于申某甲出示的保证书，申某乙庭审中对其真实性认可，应视为对赋予申某甲居住权的自认。申某甲基于该保证书认为自己已经具有案涉房屋的居住权，并长期居住在该房屋内，双方为申某甲设立居住权的意思表示已经达成一致，应视为双方达成居住权设立合同。

最后，居住权制度广泛适用于婚姻家庭领域，而在该领域中法律认可遗嘱这一单方法律行为是设立居住权的重要形式。^①据此可以看出，法律并不排除以单方法律行为设立居住权。因此，当事人在婚姻家庭领域，同样可以基于遗嘱以外的单方允诺等形式为他人，尤其是家人创设居住权。如此理解，才利于家庭关系和社会秩序的稳定。在居住权制度创设之初，认可单方允诺行为可以设立居住权，有利于发挥其稳固家庭伦理之功能。因此，当事人可以基于双方书面合同约定获得居住权，亦可以基于能够确认双方意思表示一致的所有权人的单方允诺行为而设立居住权。

二、未经登记的居住权与所有权冲突之权利保护